

1501971-59.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501971-59.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501971-59.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2285995/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20921728 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3233/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2285995 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 3233/21/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR MARTINELLI DUTRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

CAIO CESAR MARTINELLI DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia

20 de outubro de 2021, às 00h04, na Rua Isabel Maria Rodrigues, nº 01, Jardim São Guilherme II, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, para entregar a consumo de outrem, 17 (dezesete) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 3,54g; 37 (trinta e sete) microtubos plásticos contendo cocaína, na sua forma conhecida como crack, com peso líquido de 7,21g; e 14 (catorze) embalagens plásticas contendo cocaína, na sua forma conhecida como crack, com peso líquido de 4,78g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), e laudo de constatação (fls. 13/18), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 04/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação (fls. 13/18), Folhas de Antecedentes (fls. 41/42), Certidões de Distribuições Criminais (fls. 43/44) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 83/85).

Oferecida a denúncia (fls. 68/70), o réu foi notificado e citado (fl. 93) e apresentou defesa preliminar (fl. 97), após o que a denúncia foi recebida (fls. 98).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado em seguida. Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Sobre a pena, considerando a quantidade e diversidade de drogas, aguardo aumento de 1/6 (um sexto) na primeira fase. Considerando possuir uma condenação por tráfico, indicativa de seu envolvimento orgânico com o tráfico, deve ser afastado o benefício de traficante eventual. Por fim, aguarda-se regime inicial fechado, negando-se eventual recurso em liberdade. A Defesa por sua vez, requereu, em sede de preliminar, a declaração da nulidade da prova, tendo em vista que os guardas civis não teriam competência para revistar cidadãos. Nula, portanto, a prova de materialidade, impondo-se a absolvição do réu. Ainda que assim não o seja, de toda forma espera-se a absolvição de Caio Cesar, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, caso venha a ser condenado, espera-se que sejam observados os seguintes aspectos a respeito da dosimetria da sanção a ser aplicada: Em primeira etapa, não há motivos que justifiquem o incremento. As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal são favoráveis e o móvel é normal à espécie. No mais, são relativamente poucas porções encontradas, indicativo de que se trataria de traficante sem qualquer tipo de relevância no mundo do crime. No mais, é tecnicamente primário e não registrou antecedentes enquanto menor de idade. Em terceira fase, espera-se a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos. Caio Cesar foi preso em diligência fortuita e não era conhecido pelos guardas, o que seria o caso se fosse vendedor contumaz, até porque declararam que patrulhavam a região de maneira frequente. Espera-se, ainda, seja aplicada a redução prevista no artigo 41, da Lei de Tóxicos. Segundo os guardas, CAIO colaborou e indicou onde estariam as demais drogas guardadas, o que seria impossível de descobrir não fosse sua atitude. Aguarda-se, pois, a redução na proporção de 2/3. Espera-se, ainda, a eleição do regime aberto. Em caráter subsidiário, apenas, caso recusada a aplicação do redutor, requer-se o estabelecimento do regime semiaberto, porque favoráveis as circunstâncias judiciais porque a sanção será inferior a oito anos de reclusão. Ato contínuo, foi proferida a seguinte sentença: " "Vistos. CAIO CESAR MARTINELLI DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia 20 de outubro de 2021, às 00h04, na Rua Isabel Maria Rodrigues, nº 01, Jardim São Guilherme II, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, para entregar a consumo de outrem, 17 (dezesete) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 3,54g; 37 (trinta e sete) microtubos plásticos contendo cocaína, na sua forma conhecida como crack, com peso líquido de 7,21g; e 14 (catorze) embalagens plásticas contendo cocaína, na sua forma conhecida como crack, com peso líquido de 4,78g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), e laudo de constatação (fls. 13/18), o

que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/03), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 04/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação (fls. 13/18), Folhas de Antecedentes (fls. 41/42), Certidões de Distribuições Criminais (fls. 43/44) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 83/85). Oferecida a denúncia (fls. 68/70), o réu foi notificado e citado (fl. 93) e apresentou defesa preliminar (fl. 97), após o que a denúncia foi recebida (fls. 98). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado em seguida. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO. DA QUESTÃO PRELIMINAR. Afasto, inicialmente, eventual nulidade decorrente da diligência efetivada pela guarda civil municipal. Não há razão, salvo melhor juízo, para afastar a legitimidade da ação da guarda civil municipal. A ação dos guardas municipais restringiu-se a abordar o réu, durante patrulhamento de rotina, que visava próprios municipais, pois aconteceu próximo de uma escola e avistaram o réu, que ao perceber a presença da viatura tentou fugir, mas foi contido, com entorpecente e confessou o delito. No mérito, a presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que os réus praticaram o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fls. 10/11) foi submetido à prévia constatação (fls. 13/18) e a exame químico-toxicológico (fls. 83/85), sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo de 17 porções de cocaína, com peso líquido total de 3,54g; além de cocaína na forma de crack, divididos em 51 porções, com peso líquido de 11,99g; além de dinheiro, o que revela a existência de tráfico e afasta a desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Para reconhecimento do delito, desnecessária da comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento, além da apreensão de dinheiro, são suficientes para conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. É que para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia. A propósito, já se decidiu que: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade - Precedentes - Ausência de atos de mercancia - Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo - Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado - Expressa previsão legal RECURSOS IMPROVIDOS" (Apelação Criminal nº 0010719-70.2007.8.26.0495, Rel. Silmar Fernandes, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2012). "TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Réus detidos na posse de papérolas de cocaína - Quantidade e acondicionamento da droga evidenciando o comércio ilícito - Credibilidade, ademais, do testemunho dos policiais que fizeram a apreensão - Recurso parcialmente provido" (Apelação Criminal n.º 180.224-3 - São Paulo - Relator: GONÇALVES NOGUEIRA - CCRIM 3 - v.u. - 03.04.95). A autoria também restou devidamente comprovada com os relatos carregados aos autos. O guarda municipal Giuseppe Alexandro Bona relatou que na data dos fatos, estava em patrulhamento, com seu colega de farda, pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas e avistaram na via pública próximo a escola municipal Professor Amin Cassar o réu à pé em atitude suspeita, assim, o abordaram e na sua posse estavam com porções de entorpecentes nas mãos e uma sacola, também com drogas e R\$29,00 em notas trocadas. O réu confessou a prática do delito e indicou onde escondia o restante das drogas, que estava em uma área verde, que não seria localizado, sem a informação precisa de Caio. O réu afirmou que seu turno se iniciava a meia noite e terminava após vender toda a droga. Ainda, disse que estava há dois meses traficando. Não conhecia o réu, que estava sozinho no local. Não percebeu nenhuma lesão no rosto do réu. No mesmo sentido o depoimento do também guarda municipal Wagner Roberto De Souza. O réu manteve-se calado na fase

policial (fl. 06) e em Juízo negou a prática do delito. A propósito, Caio Cesar Martinelli Dutra disse que estava usando drogas, próximo de um córrego, quando foi abordado pelos guardas. A droga apresentada estava na mata e pertencia a traficantes. Conhecia os guardas de outras abordagens. Inclusive eles o agrediram. Não teve chance de falar na delegacia sobre as agressões. Na fase policial, no entanto, constou que o réu optou pelo silêncio, no entanto, afirmou que não sofreu qualquer tipo de agressão física ou psicológica desde a sua prisão até a sua apresentação na delegacia. O laudo pericial de fato aponta pequena escoriação abrasiva na região frontal e no dorso nasal. Vista a audiência de custódia, o réu estava com barba e bigode, além de cabelos compridos e eventual lesão existente não chamava a atenção, especialmente porque a prisão aconteceu de madrugada. Assim, inexistente qualquer indício de que realmente as lesões apontadas pelo perito tenham sido provocadas pelos guardas. Cabe uma ressalva, que normalmente os réus na perícia já afirmam que foram vítimas de agressões por parte dos agentes da lei responsáveis pela prisão, o que também não aconteceu. Portanto, a negativa do réu, não convence. Assim, devidamente confirmada a acusação contida na denúncia. Os guardas municipais não conheciam o réu e não teria motivo para incriminá-lo. Não se pode considerar seus depoimentos como destituídos de valias, suspeitos ou impedidos, notadamente porque não estão impedidos de depor e seus depoimentos têm o mesmo valor de todo e qualquer outro testemunho. Sempre bom lembrar que os policiais, investigadores, guarda municipais, peritos, dentre outros, exercem função pública relevante e, presumidamente, cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, os guardas municipais não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. Não se pode presumir que agentes públicos, no desempenho de suas funções, tenham que adotar conduta diversa do natural apenas com o intuito de justificar as suas ações. Nesse sentido: "O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo" (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 Relator Des. Pinheiro Franco 5ª Câmara. V.U. 31.07.2008). Ressalto, que perfeitamente válida a prisão efetuada por guardas municipais. É certo que a competência dos guardas civis municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações do Município, conforme determina o §8º do art. 144 da Constituição Federal, sendo a eles permitido, todavia, efetuar prisão daquele que está em flagrância, como dita o artigo 301 do Código de Processo Penal e, após, apresentá-lo à autoridade policial ou apenas auxiliar agentes policiais em investigações criminais. Nesse sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada" (STJ, 5ª Turma, HC nº 129.932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.

15/12/2009). “A guarda municipal, prevista no § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, cifrado na dicção de HELY LOPES MEIRELLES, no “policiamento administrativo da cidade...”. A limitação de competência, no entanto, não exclui ou retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar, prática criminosa. Neste sentido, perfeitamente respaldada a atuação dos guardas municipais que, apesar de excluídos da função repressiva do crime, nem por isto ficam impedidos de prender quem se encontre em flagrante delito, ainda que transitoriamente exerça as atribuições de autoridade policial, como de resto facultado a qualquer um do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal...” (STJ, 6ª Turma, RHC nº 7.916/SP, Relator Ministro Fernando Gonçalves, j. 15.10.1998). Como se vê, a coerente e segura versão emprestada aos fatos pelos guardas municipais, sob o crivo do contraditório, cuidam de ratificar a acusação contida na denúncia. Inexiste espaço para aplicação do artigo 41, da Lei de Drogas. O réu foi preso em poder de várias porções de drogas e indicou onde estava o restante, pequena quantia, que não modificaria sua situação, pois já em flagrante delito. Além do que, mesmo que não indicasse a guarda municipal conta com canil, que sempre atua na localização de drogas na cidade e certamente localizaria o restante (pouca quantidade) sem a ajuda do réu. Para aplicação da delação (art. 41), exige a lei colaboração efetiva, que não aconteceu no caso dos autos. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA. USO DE ATOS INFRACIONAIS COMO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA DELAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. 1. Embora o ato infracional possa, na plano fático, ser tão daninho como o crime (os fatos sociais, portanto, não mudam de natureza), seria lícito concluir que, por opção do legislador, os mundos da inimputabilidade e da imputabilidade em princípio não se intercambiam em termos penais punitivos, embora a compreensão majoritária da 3ª Seção seja pela possibilidade de negativa do redutor. 2. No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, “por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.” (EResp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 3. No caso, para a negativa de aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, as instâncias de origem levaram em conta, além da quantidade de droga apreendida (407,2 gramas de crack), embalagens plásticas e balança de precisão, os atos infracionais praticados pelo paciente, quando adolescente. 4. Na sentença fez constar que o imputado possui extenso histórico de atos infracionais, inclusive por tráfico de drogas, o que foi confirmado no acórdão recorrido, ao constar que se vislumbra a dedicação do paciente “a atividades criminosas, notadamente pelos diversos atos infracionais registrados em seu histórico (Evento 4 dos autos originários), inclusive por tráfico de drogas, o que impede a incidência da benesse à hipótese em apreço”. 5. Não consta nos autos cópia da certidão do histórico dos atos infracionais praticados pelo paciente, o que inviabiliza a análise das datas dos atos e da gravidade deles, que justifiquem idoneamente o afastamento da causa de diminuição especial da pena. Contudo, deve-se considerar legítima a decisão da Corte estadual ao indicar que há um extenso histórico infracional, e que esse histórico é grave, pois essa instância é que deve reexaminar fatos e provas. 6. Em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa. O procedimento do habeas corpus não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (AgRg no HC n. 289076/SP – 5ª T. unânime Rel. Min. Regina Helena Costa DJe 19/5/2014; AgRg no HC n. 291366/PE – 6ª T. unânime Rel. Min. Rogério Schietti Cruz DJe 29/5/2014; HC n. 269077/PE 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior DJe 2/6/2014). 7. Acerca da causa de diminuição de pena do

art. 41 da Lei 11.343/2006, a redução por informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação (HC 242.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015), o que não se deu na hipótese. 8. Habeas corpus denegado". (HC 660.874/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). No mais, o réu Caio foi preso em flagrante delito em 20.01.2021 pelo mesmo crime e foi condenado definitivamente em fevereiro deste ano a pena privativa de liberdade. E antes de sua condenação foi colocado em liberdade e cometeu este delito em 20 de outubro do mesmo ano. Assim, muito embora seja primário, havia há pouco tempo sido beneficiado pela liberdade provisória, pela prática de delito da mesma espécie, quando praticou o presente crime, afirmando para os policiais que estava no tráfico há cerca de dois meses, evidenciando sua personalidade criminosa, bem como sua dedicação ao comércio espúrio, que afastada a possibilidade de aplicação do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (fl. 47/48). Passo a dosimetria da pena. Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar, vez que ausentes outras circunstâncias ou causas que autorizem sua modificação. Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária. O réu não faz jus a qualquer benefício, diante da gravidade concreta do delito, personalidade deturpada e da pena fixada. Ademais, não olvidemos que o delito de tráfico ilícito de drogas é equiparado aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com qualquer benefício. Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu CAIO CESAR MARTINELLI DUTRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, considerando o quantum de pena fixado, e, mais ainda, a gravidade concreta do crime, especialmente no caso dos autos, que o réu já possui uma condenação definitiva pelo mesmo crime, por fato acontecido anteriormente ao crime aqui tratado. Fixado o regime inicial para o cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de adequação, neste processo, como exigência constitucional da correta individualização da pena. O réu permanece preso cautelarmente desde 20 de outubro de 2021 (fls. 01/02) e, considerando o montante da pena aplicada, observo que ele não cumpriu 40% (quarenta por cento) da pena privativa de liberdade durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à adequação, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo o regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal. Não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o processo, inexistindo alteração dos motivos que ensejaram a custódia cautelar, reavaliados recentemente nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a permitir recurso em liberdade. Portanto, a custódia deve de ser mantida, máxime pela necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo crescente tráfico de drogas. O tráfico de entorpecentes fomenta a prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, desagrega lares, destrói famílias, provocando pânico e temeridade social, principalmente no caso concreto dos autos, em que o réu, agraciado uma vez com o benefício da liberdade provisória, no mesmo ano, pela prática do mesmo delito, trazia consigo, em via pública, no período noturno entorpecentes e afirmou que já tinha voltado para o crime há pelo menos dois meses, a evidenciar o perigo que representa se estado de liberdade, não só a recomendar, mas exigir que permaneça segregado da sociedade. Ademais, importante destacar que consta na F.A. juntada aos autos, Lucas embora seja primário, foi solto uma vez pela prática de delito da mesma espécie, em curto espaço de tempo, indicando que fato tratado nos autos não é isolado e que se volta

à prática reiterada

de crimes. Além disso, ausentes nos autos indicativos seguros de ocupação lícita ou residência fixa, restando claro, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Portanto, sendo o delito em apreço é abstrata e, sobretudo, concretamente grave, e as condições pessoais desfavoráveis e, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, entendo existir nada nos autos que indique, com segurança, que quaisquer outras medidas alternativas à prisão sejam suficientes para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e eventual aplicação da lei penal. Recomende-se o réu na unidade prisional onde se encontra recolhido. A quantia apreendida em poder do réu deverá ter a destinação prevista no artigo 63, da Lei nº 11.343/06. As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, estando suspensa a exigibilidade em relação ao réu, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário. (fls. 146/154)"

Em seguida, o réu Caio Cesar foi devidamente intimado da presente sentença, tomando ciência e acabou no presente ato manifestando o interesse em recorrer para Segunda Instância. Ato contínuo, o recurso foi devidamente recebido, determinando-se seja certificado, se for o caso, o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Determinou-se ainda a Expedição da Guia de Execução Provisória em relação ao citado réu, abrindo oportunamente vista à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Com a juntada nos autos, determinou-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões.

A Defesa apresentou as razões de apelação (fls. 171/178), sendo as contrarrazões apresentadas pelo ilustre Parquet (fls. 183/189), determinando-se a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 190).

Por votação unânime, foi negado provimento ao recurso (fls. 212/220), sendo o v. Acórdão disponibilizado no DJE em 14/07/2022 (fl. 221).

As partes foram intimadas do v. acórdão (fls. 226/227), transitando em julgado em 18/08/2022 para a Defesa e em 03/08/2022 para o Ministério Público (fl. 228).

Os autos foram recebidos em cartório (fl. 230), sendo determinada a expedição de ofício em aditamento da Guia de Recolhimento Provisória à VEC competente, bem como ofícios ao IIRGD e TER comunicando-se o julgado (fls. 231/232).

Foram realizados os cálculos da pena de multa, tendo as partes concordado com os valores, sendo então homologados, determinando-se a expedição da certidão de sentença (fl. 248).

A Defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, sendo concedida a ordem para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e as delas decorrentes, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito (fls. 259/268).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 06/07, pelo laudo de constatação, pelo boletim de ocorrência e através do laudo toxicológico definitivo, a prova dos autos bem como a forma como se deu a prisão em flagrante não autorizam procedência do feito.

A testemunha Giuseppe Alexandro Bona, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, com seu colega de farda, pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas e avistaram na via pública próximo a escola municipal Professor Amin Cassar o réu à pé em atitude suspeita, assim, o abordaram e na sua posse estavam com porções de entorpecentes nas mãos e uma sacola, também com drogas e R\$29,00 em notas trocadas. O réu confessou a prática do delito e indicou onde escondia o restante das drogas, que estava em uma área verde, que não seria localizado, sem a informação precisa de Caio. O réu afirmou que seu turno se iniciava a meia noite e terminava após vender toda a droga. Ainda, disse

que estava há dois meses traficando. Não conhecia o réu, que estava sozinho no local. Não percebeu nenhuma lesão no rosto do réu.

No mesmo sentido o depoimento do também guarda municipal Wagner Roberto De Souza. O réu manteve-se calado na fase policial (fl. 06) e em Juízo negou a prática do delito.

A propósito, Caio Cesar Martinelli Dutra disse que estava usando drogas, próximo de um córrego, quando foi abordado pelos guardas. A droga apresentada estava na mata e pertencia a traficantes. Conhecia os guardas de outras abordagens. Inclusive eles o agrediram. Não teve chance de falar na delegacia sobre as agressões. Na fase policial, no entanto, constou que o réu optou pelo silêncio, no entanto, afirmou que não sofreu qualquer tipo de agressão física ou psicológica desde a sua prisão até a sua apresentação na delegacia.

O laudo pericial de fato aponta pequena escoriação abrasiva na região frontal e no dorso nasal. Vista a audiência de custódia, o réu estava com barba e bigode, além de cabelos compridos e eventual lesão existente não chamava a atenção, especialmente porque a prisão aconteceu de madrugada. Assim, inexistiu qualquer indício de que realmente as lesões apontadas pelo perito tenham sido provocadas pelos guardas.

Cabe uma ressalva, que normalmente os réus na perícia já afirmam que foram vítimas de agressões por parte dos agentes da lei responsáveis pela prisão, o que também não aconteceu.

Passo a valorar a prova.

A narrativa da denúncia não está cabalmente comprovada.

Há duas versões sobre os fatos: aquela apresentada pelos guardas municipais e a versão do acusado.

Os guardas municipais afirmaram que o réu estava em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, avistá-lo, Caio apresentou atitude suspeita, sendo desta feita realizada a abordagem; oportunidade em que localizaram drogas em seu poder. Afirmaram que o acusado confessou o comércio espúrio, indicando inclusive onde escondia o restante das drogas, esclarecendo a forma em que efetuava a mercancia, bem como horário. De outro giro, Caio César afirmou que estava tão somente consumindo drogas pelo local, tratando-se de usuário, esclarecendo que as drogas localizadas na mata pertenciam ao verdadeiro traficante.

É cediço que deve existir fundada suspeita que justifique a realização de busca pessoal, de modo que deve haver elementos concretos que impliquem suspeita de prática criminosa, não sendo permitido às guardas municipais realizar busca pessoal como decorrência de atividade de investigação criminal.

No presente caso, a atuação dos guardas municipais não se baseou em nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, mas em fatos que não chegaram nem mesmo a se tratar da famigerada "atitude suspeita" por parte do acusado.

Os entorpecentes foram encontrados após realização de busca pessoal, o que constitui verdadeira atividade de investigação que extrapola as competências constitucionais e legais previstas para as guardas civis municipais.

O crime de tráfico ilícito de drogas ora imputado ao acusado, embora seja crime permanente, só foi constatado depois da revista pessoal pelos guardas civis, que não são policiais, o que evidencia a irregularidade por ausência de causa justa e prévia.

Nesse cenário, tem-se que a busca pessoal foi realizada em atividade ostensiva de policiamento em via pública, o que não se coaduna com as funções dos guardas civis.

A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição)

decorreu de opção expressa do legislador constituinte “apesar das investidas em contrário “por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. 2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil “em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência “estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais “apesar da sua relevância “não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal. 3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar “em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais “o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros. 4. A exemplificar a patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora “alguns até mesmo de porte bastante diminuto “estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas. 5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. 6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. 8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas

sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. 9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais “e por isso interpretadas restritivamente” nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. 10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito. 11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese. 12. Recurso especial provido. (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Por conseguinte, constatado que houve o desempenho de nítida atividade de investigação pelos guardas civis, que desborda da situação de flagrância, deve ser reconhecida a invalidade das provas dela decorrentes e, consequentemente, o réu deve ser absolvido.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do feito e, consequentemente, ABSOLVO o réu CAIO CESAR MARTINELLI DUTRA das imputações constantes da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Formada a coisa julgada, arquivem-se os autos.

P. R. I.C.

Sorocaba, 22 de novembro de 2022.

MARGARETE PELLIZARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA